



DIALOG
PONAD
KULTURAMI

MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRAWO



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Sfinansowano w ramach projektu „Inkubator Włączenia Społecznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wszystkie elementy innowacji zostały udostępnione na podstawie
[Licencji Creative Commons CC.BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Zarys tematyki poruszonej przez w filmie:

KONWENCJA HASKA I EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA

Najważniejszymi źródłami prawa regulującymi sytuacje transgranicznych porwań rodzicielskich są:

- Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z dnia 25 września 1995 r.), dalej zwana „**Konwencją Haską**”
- Europejski Nakaz Aresztowania wprowadzony decyzją ramową Rady UE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi, dalej zwany „**ENA**”

ZAKRES ZASTOSOWANIA KONWENCJI HASKIEJ

Konwencja Haska została ratyfikowana przez 102 (sto dwa) państwa, w tym przez Polskę, Francję, Niemcy, ale też przez państwa spoza Europy jak przykładowo: Gwatemala, Kazachstan, Izrael.

Konwencja znajduje zastosowanie w sytuacji transgranicznego porwania rodzicielskiego dziecka i dotyczy:

- każdego dziecka, do momentu osiągnięcia 16 roku życia,
- które miało miejsce stałego pobytu w Umawiającym się Państwie bezpośrednio przed naruszeniem praw do opieki lub odwiedzin i zostało uprowadzone lub zatrzymane w innym Umawiającym się Państwie (uprowadzenie/zatrzymanie międzynarodowe).

Konwencja nie będzie miała zastosowania do uprowadzenia lub zatrzymania dziecka w granicach tego samego kraju.

O miejscu stałego pobytu dziecka nie decyduje wola osób, pod których pieczę dziecko przebywa, czy też ich zamiar stałego pobytu w danym miejscu. Miejsce stałego pobytu jest determinowane przez obiektywne fakt uzewnętrzniające długotrwałe i stabilne przebywanie dziecka w miejscu, w którym zaspakaja ono wszystkie swoje potrzeby. (postanowienie Sądu Najwyższego z 26 września 2000 r., i CKN 776/00) np. fakt uczęszczania do szkoły, fakt wynajmowania i stałego korzystania z mieszkania

Celem Konwencji jest:

- zapewnienie niezwłocznego powrotu dziecka **bezprawnie uprowadzonego** lub **zatrzymanego w** jednym z Umawiających się Państw oraz
- zapewnienie poszanowania praw do opieki i odwiedzin określonych przez ustawodawstwo jednego Umawiającego się Państwa w innych Umawiających się Państwach.

Prawo do opieki rozumiane w polskiej nomenklaturze prawnej jako prawo do pieczy, należy interpretować szeroko i może wynikać w szczególności z mocy samego prawa (władza rodzicielska), z orzeczenia sądowego lub administracyjnego (ustanowienie opieki, kurateli) albo z ugody mającej moc prawną w świetle przepisów ustawodawstwa tego państwa.

Bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie, w rozumieniu Konwencji, występuje wówczas gdy:

- nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego określonej osobie, instytucji lub innej organizacji, wykonywanego wspólnie lub indywidualnie, na mocy ustawodawstwa państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem, **oraz**
- w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawa te były skutecznie wykonywane wspólnie lub indywidualnie albo byłyby tak wykonywane, gdyby nie nastąpiło uprowadzenie lub zatrzymanie.

Oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Bezprawne uprowadzenie następuje w chwili przekroczenia przez dziecko granica państwa, w którym ma stały pobyt, bez wymaganej zgody osoby, której przysługuje prawo do opieki nad nim.

Prawem właściwym dla dokonania oceny bezprawności uprowadzenia lub zatrzymania jest prawo tego państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem.

PROCEDURY

Zadaniem Konwencji nie jest rozstrzygnięcie w przedmiocie prawa do opieki, czy o miejscu pobytu dziecka, ale przywrócenie stanu poprzedniego naruszonego bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem. Potwierdził to Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 4 lutego 1998 r., i CKN 921/97 stwierdzając, że „W postępowaniu uregulowanym postanowieniami Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. 1995 r. Nr 108, poz. 528), kognicją sądu nie jest objęte - poza art. 16 - rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej.”

Rozstrzygnięcie sądu wydane na gruncie Konwencji Haskiej nie rozstrzyga o sposobie sprawowania pieczy nad dzieckiem w przyszłości. Takie orzeczenie jest neutralne także wobec innych postępowań dotyczących sprawowania pieczy (władzy rodzicielskiej). Kwestia sprawowania pieczy nad dzieckiem powinna zostać rozstrzygnięta przez sąd właściwy dla miejsca stałego pobytu dziecka, po jego powrocie.

W tym celu rodzic, opiekun, kurator składa wniosek o nakazanie powrotu dziecka/wniosek o zwrot dziecka/wniosek o powrót dziecka do:

- organu centralnego miejsca stałego pobytu dziecka, bądź
- organu centralnego państwa, do którego dziecka zostało bezprawnie uprowadzone lub zatrzymane.

Organem centralnym w Polsce jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które w zakresie realizacji kompetencji wynikających z Konwencji Haskiej działa na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 (Dz.U.2018, poz.416) o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych .

Wniosek powinien zawierać:

- informacje dotyczące tożsamości wnioskodawcy, dziecka oraz osoby, co do której istnieje domniemanie, że uprowadziła lub zatrzymała dziecko;
- datę urodzenia dziecka, jeśli jest to możliwe do ustalenia;
- podstawy, na które powołuje się wnioskodawca, żądając powrotu dziecka;
- wszelkie dostępne informacje dotyczące miejsca przebywania dziecka oraz tożsamości osoby, co do której istnieje domniemanie, że dziecko z nią przebywa.

Do wniosku można dołączyć lub uzupełnić go o:

- uwierzytelnione odpisy jakiegokolwiek orzeczenia lub ugody, przydatne dla sprawy;
- zaświadczenie lub poświadczony oświadczenie pochodzące od organu centralnego lub innej właściwej władzy państwa stałego pobytu dziecka lub osoby kompetentnej, dotyczące przepisów ustawodawstwa tego państwa w tym zakresie;
- wszelkie inne przydatne dokumenty.

Wniosek powinien być sporządzony w dwóch wersjach językowych: w języku urzędowym państwa stałego pobytu dziecko i w języku urzędowym państwa

do którego dziecko zostało bezprawnie uprowadzone lub w którym zostało bezprawnie zatrzymane. Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości jako organ centralny publikuje na swojej stronie internetowej wzory formularzy wniosku o nakazanie powrotu dziecka.

Po zweryfikowaniu wniosku pod kątem formalnoprawnym Ministerstwo Sprawiedliwości przekazuje poprawny formalnie wniosek do właściwego sądu opiekuńczego. Dopiero od 2018 r. w polskim Kodeksie postępowania cywilnego została uregulowana procedura odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzona na podstawie konwencji haskiej.

Konwencja narzuca zasadę, że **sąd opiekuńczy jest zobowiązany zarządzić niezwłoczne wydanie dziecka jeżeli od momentu bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka do momentu złożenia wniosku o powrót dziecka upłynął okres krótszy niż rok.** Od tej zasady istnieją wyjątki, które zostaną opisane poniżej.

Termin rozpoznania sprawy z wniosku o powrót dziecka nie powinien przekroczyć 6 (sześciu) tygodni. Jest to termin wynikający z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego regulujących procedurę w sprawach o odebranie osoby małoletniej. Podobnie, Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, stanowi w art. 11 ust 3, że sąd wydaje orzeczenie nie później niż 6 (sześć) tygodni od wniesienia wniosku, chyba, że na skutek nadzwyczajnych okoliczności nie jest to możliwe.

W wyroku z dnia 19 lipca 2016 r., 2171/14 Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał, że „sześciotygodniowy termin do rozpoznania przez sąd krajowy wniosku o powrót dziecka do miejsca zamieszkania na mocy Konwencji haskiej nie jest

obligatoryjny. Jednakże, przekroczenie go o sześćdziesiąt cztery tygodnie przy braku jakichkolwiek okoliczności mogących zwolnić sądy krajowe z jego ścisłego przestrzegania, nie licuje z powagą sytuacji i nie jest zgodny z pozytywnym obowiązkiem działania bez zbędnej zwłoki w postępowaniu o powrót dzieci, co narusza artykuł 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284)."

Przykład:

W lipcu 2014 obywatelka Francji wyjechała wraz z małoletnią córką, pochodzącą z nieformalnego związku, do Polski. Wyjazd małoletniej odbył się bez wiedzy i zgody jej ojca, także obywatela Francji. na skutek kroków prawnych podjętych przez ojca, w lutym 2015 r. sąd francuski ustalił miejsca zamieszkania małoletniej przy ojcu. Ponadto, w listopadzie 2014 ojciec dziecka skierował do francuskiego organu centralnego wnioski o wydanie małoletniej trybie Konwencji Haskiej, który został przekazany do polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości jako organu centralnego, a następnie w kwietniu 2015 r. do właściwego miejscowo i rzeczowo sądu. w trakcie postępowania matka z dzieckiem z dnia na dzień wyjechały z miejscowości, w której było prowadzone postępowanie. Przypuszczano, że wyjechały do innego państwa UE, albo wróciły do Francji.

Sąd rozpoznający sprawę stwierdził, że w przedstawionym stanie faktycznym doszło do bezprawnego uprowadzenia dziecka. Przywołał także regulację Konwencji, że jeżeli dziecko zostało bezprawnie uprowadzone lub zatrzymane, a w chwili wpłynięcia wniosku do władzy sądowej lub administracyjnej Umawiającego się Państwa, w którym znajduje się dziecko, upłynął okres krótszy niż jeden rok od dnia uprowadzenia lub zatrzymania, należy zarządzić niezwłoczne wydanie dziecka. Jednak sąd zważył, że decyzja o wydaniu dziecka nie następuje automatycznie. Pomimo bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania, wniosek o powrót dziecka może zostać oddalony, jeżeli:

→ *istnieją podstawy by sądzić, że dziecko zostało zabrane do innego państwa;*

→ *istnieją przesłanki, aby twierdzić, że na zarządzenie powrotu mogłoby naruszyć dobro dziecka, w rozumieniu opisanym poniżej.*

W rzeczonyj sprawie sąd oddalił wniosek o zwrot dziecka.

POJĘCIE „DOBRA DZIECKA” na GRUNCIE KONWENCJI HASKIEJ

Pomimo tego, że głównym założeniem Konwencji Haskiej jest przywrócenie stanu sprzed bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka to jednak nie pozwala ona na działania wyzbyte jakiejkolwiek analizy dobra dziecka. Konwencja Haska, podobnie jak Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526) stoi na straży dobra dziecka i uznaje interesy dziecka za wartość nadrzędną. Dlatego też, nie ma obowiązku zarządzenia wydanie dziecka:

1. jeżeli osoba, instytucja lub organizacja sprzeciwiająca się wydaniu dziecka wykaże, że:
 - osoba, instytucja lub organizacja opiekująca się dzieckiem faktycznie nie wykonywała prawa do opieki w czasie uprowadzenia lub zatrzymania albo zgodziła się lub później wyraziła zgodę na uprowadzenie lub zatrzymanie; lub
 - istnieje poważne ryzyko, że powrót dziecka naraziłby je na szkodę fizyczną lub psychiczną albo w jakikolwiek inny sposób postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia.
2. jeżeli dziecko sprzeciwia się powrotowi oraz że osiągnęło ono wiek i stopień dojrzałości, przy którym właściwe jest uwzględnienie jego opinii.

Z orzecznictwa:

- ideą Konwencji jest, aby w przypadku spełnienia pozytywnych przesłanek automatycznie zarządzić powrót dziecka. Jednak to nie oznacza, że sąd nie jest zobowiązany do badania przesłanek uzasadniających odmowę nakazania powrotu dziecka. w tym zakresie Sąd posiada inicjatywę dowodową i jest

zobowiązany do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości pojawiających się w toku postępowania dowodowego: → tak postanowienie Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2021 r. i CSKP 360/21 „przy spełnieniu pozytywnych przesłanek zarządzenia powrotu dziecka zachodzi swoisty automatyzm. Jednakże jest on weryfikowany przesłankami uzasadniającymi odmowę nakazania powrotu dziecka, z jednej strony wymagającymi ścisłej interpretacji, ale z drugiej strony na tyle pojemnymi, że pozwalają one na urzeczywistnienie jednej z podstawowych zasad prawa rodzinnego, a mianowicie dobra dziecka. Oczywiście, aby nie zamazać idei sporządzenia Konwencji haskiej i wprowadzenia jej w życie, ocena ewentualnych podstaw odmowy powrotu dziecka musi być poprzedzona wnikliwym postępowaniem dowodowym, nie wyłączając inicjatywy dowodowej podjętej przez Sądy meriti z urzędu, oraz wyczerpaniem wszelkich możliwości sprawdzenia sytuacji dziecka z punktu widzenia jego dobra. Innymi słowy, jeżeli pojawiają się w tym zakresie jakiegokolwiek wątpliwości, to bezwzględnie muszą zostać zweryfikowane. Brak tu miejsca na jakiegokolwiek niejasności wynikające chociażby z faktu niewykazania określonych okoliczności przez uczestnika postępowania. Oczywiście, Sądy nie mają obowiązku prowadzenia w tym zakresie dochodzenia, jak miało to miejsce w czasie obowiązywania zasady prawdy obiektywnej, ale w większym niż zazwyczaj zakresie powinny sięgać do art. 232 zd. 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., czego przykładem może być postępowanie Sądu ad quem.

- **nie można nakazać powrotu dziecka wbrew jego woli, jeżeli doprowadziłoby to zerwania naturalnych więzi rodzinnych i środowiska dziecka, w których dziecko wzrastało od urodzenia, zakłócając jego rozwój edukacyjny, emocjonalny i socjalizujący** → tak postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2020 r. i ACa 177/20 „powrót dziecka nie może być nakazywany automatycznie lub mechanicznie, gdy znajduje zastosowanie

Konwencja haska, w szczególności w świetle pomieszczenia w niej szeregu wyjątków od obowiązku powrotu dziecka. Czynniki, które mogą stanowić wyjątek od natychmiastowego powrotu dziecka, zwłaszcza gdy zostały podniesione przez jedną ze stron postępowania, muszą zostać autentycznie uwzględnione przez sąd, do którego się zwrócono o nakazanie wydania dziecka. Sąd ten musi wówczas wydać rozstrzygnięcie, które jest w wystarczająco uzasadnione w tej mierze. Jak podkreślił, najlepsze interesy dziecka muszą mieć znaczenie nadrzędne. Gdyby więc nawet przyjąć, ku czemu nie ma podstaw, że ów sprzeciw małoletniej z uwagi na wiek nie jest dostatecznie dojrzały, w świetle obiektywnie usprawiedliwionych i podniesionych zarówno przez Uczestnika jak i dziecko przyczyn, stanowiłby wypełnienie przesłanki z art. 13 zd. 1 pkt b Konwencji, albowiem wbrew woli dziecka i jego dobru, zrywałby naturalne więzi rodzinne i środowisko dziecka, w których małoletnia wzrastała od urodzenia, zakłócając jej rozwój edukacyjny, emocjonalny i socjalizujący.

- „odmowę nakazania powrotu dziecka uzasadnia tylko taka szkoda fizyczna lub psychiczna, która stawia dziecko w sytuacji nie do zniesienia, przy czym ryzyko takiej szkody, podobnie jak ryzyko powstania innej sytuacji, która byłaby dla dziecka nie do zniesienia, musi być poważne. Niewystarczające są natomiast wszelkie inne uciążliwości i niedogodności” → postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2021 r. i CSKP
- **akty przemocy domowej, wobec dziecka, czy wobec rodzica są uzasadnioną przesłanką do odmowy powrotu dziecka** → tak postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2021 r., i NSNc 36/21, w którym stwierdzono, że: „ obserwowanie zarówno samych aktów przemocy wobec matki, jak i jej skutków, ma w świetle doświadczenia życiowego poważne reperkusje dla rozwoju i postawy dziecka. Może prowadzić do jego demoralizacji, a co najmniej

utrwalania niemożliwej do zaakceptowania w polskim porządku konstytucyjnym, którego aksjologicznym jądrem jest gwarancja równej godności człowieka - "normy" wyższości jednego z małżonków.

Poważne ryzyko przemocy względem dziecka, a wyjątkowo również względem rodzica, który dopuścił się bezprawnego zatrzymania lub uprowadzenia dziecka i zamierzałby z nim powrócić, jeżeli kreowałoby to sytuację nie do zniesienia dla dziecka, uzasadnia zastosowanie art. 13 akapit 1 lit. b Konwencji haskiej. Podstawa do odmowy wydania dziecka zachodzi przed wszystkim w sytuacji wykazania, że dochodziło do aktów przemocy domowej wobec dziecka lub jego seksualnego wykorzystywania w miejscu stałego pobytu albo patologicznych zachowań na tle uzależnienia lub choroby psychicznej wnioskodawcy. Sąd Najwyższy podkreślał również, że zwłaszcza poważne ryzyko przemocy względem dziecka, a wyjątkowo również względem rodzica, który dopuścił się bezprawnego zatrzymania lub uprowadzenia dziecka i zamierzałby z nim powrócić, jeżeli kreowałoby to sytuację nie do zniesienia dla dziecka, uzasadnia zastosowanie art. 13 akapit 1 lit. b Konwencji haskiej."

- ale „nie uzasadniają odmowy nakazania powrotu dziecka co do zasady takie okoliczności, jak integracja dziecka w nowym środowisku, pod warunkiem, że wniosek został złożony przed upływem rocznego terminu (art. 12 ust. 1 i 2 Konwencji haskiej), skromniejsze warunki bytowe dziecka, niższy standard opieki zdrowotnej lub niedostateczne kompetencje wychowawcze ze strony rodzica ubiegającego się o powrót dziecka, co podlega ocenie w postępowaniu dotyczącym opieki nad dzieckiem.” → tak postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2020 r. i CSK 183/20
- ale sam fakt oddzielenia od matki w zasadzie nie może stać na przeszkodzie powrotowi bezprawnie uprowadzonego dziecka do państwa miejsca jego

stałego pobytu → tak postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 1999 r., i CKN 992/99

Ponadto, zgodnie z art 11 ust 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, analizując kwestie dobra dziecka należy zapewnić dziecku możliwość bycia wysłuchanym w toku postępowania, o ile nie wydaje się to niewłaściwe ze względu na jego wiek lub stopień dojrzałości.

WYKONANIE ORZECZENIA O NAKAZANIU POWROTU DZIECKA

W postanowieniu o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką w sprawie prowadzonej na podstawie Konwencji Haskiej sąd nakazuje zobowiązanemu zapewnić powrót dziecka do państwa, w którym bezpośrednio przed naruszeniem prawa wynikającego z władzy rodzicielskiej lub opieki miało miejsce stałego pobytu, w **terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia**.

Postanowienie o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, **staje się skuteczne i wykonalne po uprawomocnieniu**. na postanowienie sądu i instancji przysługuje apelacja. w związku z tym, o uprawomocnieniu się postanowienia o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką można mówić dopiero wówczas, gdy apelacja nie została złożona, albo w przypadku jej złożenia, dopiero z chwilą wydania postanowienia oddalającego apelację przez sąd II instancji. Warto także wskazać, że sądem II instancji w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie Konwencji Haskiej jest zawsze Sąd Apelacyjny

w Warszawie, który powinien rozstrzygnąć sprawę w terminie sześciu tygodni od dnia przedstawienia przez sąd pierwszej instancji akt sprawy wraz z apelacją.

W sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie Konwencji Haskiej, po wyczerpaniu toku instancyjnego przed sądem I i II instancji, przysługuje skarga kasacyjna albo skarga nadzwyczajna, o której mowa w art. 89 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.

Na żądanie Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika Praw Obywatelskich zgłoszone sądowi II instancji, czyli Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie, w **terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia** w przedmiocie odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wstrzymuje się z mocy prawa wykonanie tego postanowienia. Jednak **jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia** Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Dziecka lub Rzecznik Praw Obywatelskich nie **wniesienie skargi kasacyjnej** wówczas **wstrzymanie wykonania postanowienia ustaje**. Jeżeli jednak, któryś z tych podmiotów we wskazanym terminie wniesie skargę kasacyjną wówczas wstrzymanie wykonania tego postanowienia przedłuża się z mocy prawa do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego.

Wniosek o wstrzymanie wykonania prawomocnego postanowienia w przedmiocie odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką może także złożyć sama strona tego postępowania, jeżeli wykaze, że na skutek wykonania postanowienia może być jej wyrządzona niepowetowana szkoda.

W przypadku nie wykonania dobrowolnego postanowienia sądu w przedmiocie odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, sąd na wniosek uprawnionego, zleca kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie.

NA CZYM POLEGA EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA

Europejski nakaz aresztowania jest często stosowany w sprawach porwań rodzicielskich w państwa UE. Jednak w Polsce zastosowanie ENA jest ograniczone ze względu na brak jednoznacznej regulacji porwania rodzicielskiego jako przestępstwa.

Decyzja ramowa Rady UE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi została implementowana do polskiego Kodeksu postępowania karnego w dniu 1 maja 2004 r. ENA może zostać wydany:

- gdy chodzi o postępowanie karne dotyczące czynów z mocy prawa krajowego zagrożonych karą pozbawienia wolności lub zastosowaniem środka zapobiegawczego o maksymalnym wymiarze co najmniej 12 miesięcy (podczas dochodzenia, śledztwa i procesu, aż do uprawomocnienia się wyroku skazującego) albo
- gdy chodzi o wykonanie wyroku lub zastosowanie środka zabezpieczającego w wymiarze co najmniej czterech miesięcy.

ENA służy do przekazania w ramach UE podejrzanych lub oskarżonych na potrzeby ścigania przestępstw lub wykonania wyroku pozbawienia wolności bądź zastosowania środka zabezpieczającego polegającego na pozbawieniu wolności.

Jednak w sprawach porwań rodzicielskich ENA znajduje ograniczone zastosowanie w Polsce ze względu na spór w doktrynie karnej czy porwanie rodzicielskie jest w ogóle przestępstwem.

Zgodnie z art. 211 polskiego Kodeksu karnego kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Według prof. Ryszarda A. Stefańskiego „nie można mówić o realizacji znamion przestępstwa z art. 211 w przypadku zabrania lub zatrzymania dziecka przez jedno z rodziców wbrew woli drugiego, jeśli oboje wykonują wspólnie władzę rodzicielską.” Natomiast uznaje się, że może być sprawcą ten rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub któremu została ona ograniczona lub zawieszona.

Podobnie stwierdził Sąd Najwyższy m.in. w postanowieniu z dnia 9 grudnia 2003 r., III KK 116/03, że „jeżeli sąd powierza w toku procesu o rozwód tymczasowo małoletnie wspólne dziecko poniżej lat 15 pieczy jednego rodziców, to drugi z rodziców, który uprowadza lub zatrzymuje to dziecko, nie może być podmiotem przestępstwa z art. 211 k.k., chyba że uprzednio ograniczono już jego władzę rodzicielską albo rozstrzygnięto co do sprawowania pieczy przez drugiego z rodziców w sposób podobny do ograniczenia władzy rodzicielskiej, nie zawężając tej decyzji do samego powierzenia pieczy nad dzieckiem i nakazu wydania go danemu rodzicowi, a odebranie dziecka spod pieczy godzi w to ograniczenie lub w ograniczający władzę rodzicielską sposób sprawowania pieczy.”

Z kolei Marek Mozgawa w Komentarzu do Kodeksu karnego pod jego redakcją (publ. Lex/el.2022) zwrócił uwagę, że „rodzice są zobligowani do wspólnego decydowania o miejscu pobytu małoletniego, który powinien przebywać w miejscu odpowiadającym woli obojga rodziców mających pełną władzę rodzicielską. Wykładnia gramatyczna, a także w szczególności ratio legis art. 211 k.k. nie dają podstawy do ekskulpowania rodzica, który posiadając pełną władzę rodzicielską, uprowadza dziecko wbrew woli

drugiego z rodziców, również korzystającego z pełni praw rodzicielskich. Przeciwnie stanowisko dawałoby bezkarność skłóconym rodzicom co najmniej do chwili pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej choćby jednego z nich. Wydaje się również, że – przy analogicznej argumentacji – możliwe jest popełnienie czynu zabronionego z art. 211 k.k. w postaci zatrzymania małoletniego przez rodzica mającego pełną władzę rodzicielską”

Dlatego też, polskie sądy karne często odmawiają wykonania ENA wydanego przez inne państwo EU, powołując się właśnie na argument, że przestępstwo będące podstawą wydania nakazu europejskiego, nie stanowi przestępstwa według prawa polskiego. Trudno jest także uzyskać w Polsce ENA w przypadku porwania rodzicielskiego.

PROCES TRANSGRANICZNEJ MEDIACJI W POLSCE

W obecnych realiach sądowych problemem nie jest czy mediować, ale jak mediować, aby realnie rozwiązać konflikt w szczególności o charakterze rodzinnym. Oczywistym jest, że mediacja jest prostsza, tańsza i szybsza niż postępowanie sądowe. Jednak nadal koniecznym jest szukanie odpowiedzi na pytanie **jak mediować**, aby trafić do ludzi pozostających w bardzo głębokim konflikcie, o emocjonalnym podłożu.

Wydaje się, że mediacja w sprawach rodzinnych jest szansą, nie tyle na rozwiązanie konfliktu, co na jego złagodzenie. Mediacja powinna być sposobem na zarządzenie konfliktem. Jest to bardzo trudne wyzwanie dla psychologów i socjologów, którzy powinni odgrywać pierwszoplanowe role w mediacji. Skuteczna mediacja powinna być:

1. Wolna od stereotypów;
2. Oparta na głębokiej wiedzy na temat psychologii dziecka i rodziny;
3. Oparta na zasadzie równości;
4. Wolna od nacisków i manipulacji;
5. Szanująca kulturę, religię i tradycję z której wywodzi się rodzina;

6. Gwarantować wsparcie, dawać zaufanie;
7. Nieograniczona w czasie;

PRZYDATNE LINKI:

- <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=24> – Konwencja Haska, lista aktualnych sygnatariuszy Konwencji
- https://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/abduction/index_pl.htm
- <https://www.gov.pl/web/stopuprowadzeniomdzieci/stop-uprowadzeniom-dzieci> - Ministerstwo Sprawiedliwości - organ centralny
- <https://www.gov.pl/web/stopuprowadzeniomdzieci/formularze-do-pobrania> - formularze wniosków o powrót dziecka
- [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510012/IPOL_STU\(2015\)510012_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510012/IPOL_STU(2015)510012_EN.pdf) - badanie PE dotyczące transgranicznego uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców w ramach UE
- <https://bip.brpo.gov.pl/> - Rzecznik Praw Obywatelskich
- <https://brpd.gov.pl/> - Rzecznik Praw Dziecka

Zarys tematyki poruszonej przez w filmie:

WYBRANE ASPEKTY Z ZAKRESU POLSKIEGO PRAWA RODZINNEGO

ŹRÓDŁA PRAWA REGULUJĄCE JURYSDYKCJĘ I PRAWO WŁAŚCIWE W SPRAWACH TRANSGRANICZNYCH DOTYCZĄCYCH DZIECI

Najważniejszymi źródłami prawa regulującymi jurysdykcję oraz prawo właściwe, które ma zastosowanie w sytuacjach o charakterze międzynarodowym, w sprawach dotyczących dzieci są:

- Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (Dz. U. UE L 178/1 z dnia 2 lipca 2019 roku) zwane dalej: Rozporządzenie Bruksela II ter;
- Rozporządzenie Rady (WE) NR 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. U. UE L 7/1 z dnia 10 stycznia 2009 roku), zwane dalej Rozporządzenie;
- Protokół o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzonym w Hadze w dniu 23 listopada 2007 roku (Dz.U.U.E.L.2009.331.19 z dnia 2009.12.16), zatwierdzonym decyzją Rady 2009/941/WE z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu haskiego z dnia 23 listopada 2007 roku o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.U.E.L.2009.331.17 z dnia 2009.12.16), zwany dalej: Protokołem haskim
- Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony

dzieci sporządzona w Hadze dnia 19 października 1996 roku (Dz.U.2010.172.1158 z dnia 22 września 2010 roku) zwana dalej: Konwencją;

W Polsce, aktami prawnymi regulującymi sprawy dotyczące dzieci są przede wszystkim:

- w zakresie przepisów prawa materialnego: ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U.2020.1359 z dnia 10 sierpnia 2020);
- w zakresie procedury: ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U.2021.1805 z dnia 4 października 2021)

ZAKRES ZASTOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA BRUKSELA II TER

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę ma zastosowanie i ustanawia jednolite przepisy dotyczące jurysdykcji w następujących sprawach cywilnych:

- małżeńskich dotyczących rozwodu, separacji oraz unieważniania małżeństwa;
- z zakresu odpowiedzialności rodzicielskiej dotyczące przyznania, wykonywania, przekazania, pełnego lub częściowego pozbawienia odpowiedzialności rodzicielskiej, które mogą w szczególności obejmować:
 - pieczę nad dzieckiem i prawo do osobistej styczności z dzieckiem;
 - opiekę, kuratelę i podobne instytucje prawne;
 - wyznaczenie i zakres zadań osoby lub jednostki, która jest odpowiedzialna za osobę lub majątek dziecka, lub reprezentuje je lub udziela mu pomocy;
 - umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczej lub w opiece zastępczej;

- środki mające na celu ochronę dziecka w odniesieniu do zarządu, zabezpieczenia lub rozporządzania majątkiem dziecka.

Rozporządzenie Bruksela II ter obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem Dani.

Rozporządzenie Bruksela II ter ułatwia obieg orzeczeń, dokumentów urzędowych i określonych porozumień dzięki ustanowieniu przepisów dotyczących ich uznawania i wykonywania w innych państwach członkowskich. Ponadto wyjaśnia zasady dotyczące prawa dziecka do wyrażenia swoich poglądów w ramach postępowania, które go dotyczy, a także zawiera przepisy uzupełniające Konwencję haską z dnia 25 października 1980 roku dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę w stosunkach między państwami członkowskimi.

Zasadą jest, że w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej jurysdykcję mają sądy tego państwa członkowskiego, w którym w chwili wniesienia pozwu lub wniosku dziecko ma zwykły pobyt (art. 7 Rozporządzenia Bruksela II ter).

Pojęcie zwykły pobyt dziecka należy zawsze interpretować w odniesieniu do konkretnej sprawy, na podstawie jej okoliczności faktycznych.

Taki sposób rozumienia omawianego pojęcia był prezentowany w orzecznictwie już wcześniej, a mianowicie Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 2 kwietnia 2009 roku, w sprawie: [C-523/07](#), A., w którym wskazał, że „miejsce stałego pobytu znajduje się tam, gdzie dziecko wykazuje pewną integrację ze środowiskiem społecznym i rodzinnym. Należy w szczególności wziąć pod uwagę trwałość, zgodność z prawem, warunki oraz motywy pobytu i przenosin rodziny do danego państwa członkowskiego, obywatelstwo dziecka, miejsce i warunki uczęszczania dziecka do szkoły, znajomość

języków, a także więzi rodzinne i społeczne dziecka w tym państwie członkowskim. do sądu krajowego należy ustalenie miejsca stałego pobytu dziecka w oparciu o wszystkie istotne okoliczności danego przypadku.”

Zwykły pobyt nie zawsze będzie oznaczał, że chodzi o stan długotrwały i utrwalony, ponieważ nie można wykluczyć, że w niektórych sytuacjach dziecko uzyska miejsce zwykłego pobytu zaraz po przybyciu do innego państwa członkowskiego. Przykładem takiej sytuacji może być przyjazd dziecka na terytorium innego państwa członkowskiego z zamiarem skoncentrowania w tym kraju jego interesów życiowych i uczynienie z niego centrum jego egzystencji (takiej wykładni pojęcia „zwykły pobyt” dokonał Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 8 czerwca 2017 roku, w sprawie: [C-111/17](#) PPU).

Od zasady opisanej powyżej, Rozporządzenie Bruksela II ter przewiduje wyjątki:

- w przypadku zgodnego z prawem przeprowadzenia się dziecka z jednego państwa członkowskiego do innego i uzyskania przez nie w tym państwie nowego zwykłego pobytu, jurysdykcja sądów państwa członkowskiego poprzedniego zwykłego pobytu dziecka zostaje - w drodze wyjątku - utrzymana przez okres trzech miesięcy po przeprowadzce, do celów zmiany orzeczenia dotyczącego prawa do osobistej styczności z dzieckiem wydanego w tym państwie członkowskim przed przeprowadzeniem się dziecka, jeżeli osoba, której na podstawie tego orzeczenia przyznano prawo do osobistej styczności z dzieckiem, nadal ma zwykły pobyt w państwie członkowskim poprzedniego zwykłego pobytu dziecka (art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Bruksela II ter);
- w przypadku bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka jurysdykcja sądów państwa członkowskiego, w którym dziecko bezpośrednio przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem miało zwykły pobyt,

zostaje utrzymana do chwili uzyskania przez dziecko zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim, chyba że dziecko uzyskało zwykły pobyt w innym państwie i został spełniony jeden z alternatywnych warunków przewidzianych w dalszej części tego przepisu tj. art. 9 lit. a) i b) Rozporządzenia Bruksela II ter);

- w przypadku dokonania innego wyboru przez sąd, podyktowanego związkiem dziecka z państwem członkowskim, którego sądy rozpoznają sprawę (art. 10 ust. 1 a) Rozporządzenia Bruksela II ter);
- w przypadku gdy strony dobrowolnie porozumiały się co do jurysdykcji, najpóźniej w chwili wszczęcia postępowania lub uznały wyraźnie jurysdykcję w toku tego postępowania, a sąd zapewnił, by wszystkie strony zostały poinformowane o przysługującym im prawie do odmowy uznania jurysdykcji (art. 10 ust. 1 b) Rozporządzenia Bruksela II ter);
- w przypadku gdy wykonywanie jurysdykcji jest zgodne z dobrem dziecka (art. 10 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia Bruksela II ter).

ZAKRES ZASTOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie Rady (WE) NR 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. U. UE L 7/1 z dnia 10 stycznia 2009 roku), zwane dalej Rozporządzenie ma zastosowanie do zobowiązań alimentacyjnych wynikających ze stosunku rodzinnego, pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa.

Rozporządzenie obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem Dani.

Sądami, które mają jurysdykcję do rozpoznania spraw dotyczących zobowiązań alimentacyjnych w państwach członkowskich są:

- a) sąd zwykłego miejsca pobytu pozwanego lub
- b) sąd zwykłego miejsca pobytu wierzyciela lub
- c) sąd, który zgodnie z prawem sądu ma jurysdykcję do prowadzenia postępowania dotyczącego statusu osoby, w przypadku gdy sprawa dotycząca zobowiązań alimentacyjnych jest związana z tym postępowaniem, chyba że jurysdykcja ta wynika tylko z obywatelstwa jednej ze stron lub
- d) sąd, który zgodnie z prawem sądu jest właściwy do prowadzenia postępowania dotyczącego odpowiedzialności rodzicielskiej, w przypadku gdy sprawa dotycząca zobowiązań alimentacyjnych jest związana z tym postępowaniem, chyba że jurysdykcja ta wynika tylko z obywatelstwa jednej ze stron.

Strony, na zasadach wynikających z art. 4 Rozporządzenia mogą także umówić się, że określony sąd lub sądy państwa członkowskiego mają jurysdykcję do rozstrzygania sporów już wynikłych lub mogących wyniknąć między nimi w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych.

Zgodnie z art. 5 Rozporządzenia niezależnie od jurysdykcji wynikającej z innych przepisów niniejszego rozporządzenia sąd państwa członkowskiego, uzyskuje jurysdykcję, jeżeli pozwany wda się w spór przed tym sądem. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli pozwany wdaje się w spór w celu podniesienia zarzutu braku jurysdykcji.

W art. 15 Rozporządzenie przewiduje określenie prawa właściwego, odwołując się w tym zakresie do Protokołu o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzonym w Hadze w dniu 23 listopada 2007 roku (Dz.U.UE.L.2009.331.19 z dnia 2009.12.16), zatwierdzonym decyzją Rady 2009/941/WE z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu haskiego z dnia 23

listopada 2007 roku o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE.L.2009.331.17 z dnia 2009.12.16).

Zgodnie z art. 3 Protokołu haskiego, zobowiązania alimentacyjne podlegają prawu państwa, w którym wierzyciel ma miejsce zwykłego pobytu, chyba że niniejszy protokół stanowi inaczej. w przypadku zmiany miejsca zwykłego pobytu wierzyciela stosuje się prawo państwa, w którym wierzyciel ma nowe miejsce zwykłego pobytu, od momentu, w którym nastąpiła ta zmiana.

W przypadku zobowiązań alimentacyjnych rodziców na rzecz dzieci, art. 4 Protokołu haskiego wprowadza uprzywilejowanie w zakresie prawa właściwego, a mianowicie:

- jeśli wierzyciel nie może na mocy prawa, o którym mowa w artykule 3 Protokołu haskiego, uzyskać świadczeń alimentacyjnych od dłużnika, stosuje się prawo miejsca organu orzekającego w sprawie,

podobnie:

- jeśli wierzyciel wytoczył powództwo przed właściwym organem państwa, w którym dłużnik ma miejsce zwykłego pobytu, stosuje się prawo miejsca organu orzekającego w sprawie. Jeżeli jednak wierzyciel nie jest w stanie uzyskać na mocy tego prawa świadczeń alimentacyjnych od dłużnika, stosuje się prawo państwa, w którym wierzyciel ma miejsce zwykłego pobytu;

oraz:

- jeśli wierzyciel nie jest w stanie uzyskać na mocy prawa, o którym mowa w przepisach wyżej wymienionych, świadczeń alimentacyjnych od dłużnika, stosuje się prawo państwa ich obywatelstwa, jeśli mają wspólne.

Protokół haski przewiduje również, że wierzyciel alimentacyjny i dłużnik mogą dokonać wyboru prawa właściwego, na zasadach szczegółowo opisanych w postanowieniach tego Protokołu.

ZAKRES ZASTOSOWANIA KONWENCJI

Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci sporządzona w Hadze dnia 19 października 1996 roku (Dz.U.2010.172.1158 z dnia 22 września 2010 roku) funkcjonuje obok wyżej opisanych Rozporządzeń Wspólnotowych oraz w stosunkach z państwami trzecimi, które ratyfikowały Konwencję a nie są członkami Unii Europejskiej (np. Ukraina, Republika Dominikańska, Republika Ekwadoru, Królestwo Marokańskie).

Konwencja w art. 5 reguluje ogólną zasadę dotyczącą jurysdykcji, która stanowi, że zarówno organy sądowe, jak i administracyjne Umawiającego się Państwa, w którym dziecko ma zwykły pobyt, są właściwe do podejmowania środków zmierzających do ochrony jego osoby lub majątku.

W kolejnych artykułach Konwencja reguluje sytuacje, które umożliwiają odejście od powyższej zasady. w kontekście niniejszego opracowania, na uwagę zasługuje artykuł 7 Konwencji, który stanowi, że: w razie bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka organy Umawiającego się Państwa, w którym dziecko bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem miało zwykły pobyt, zachowują swoją jurysdykcję do chwili, gdy dziecko uzyska zwykły pobyt w innym państwie, oraz:

- każda osoba, organ lub inna jednostka uprawniona do pieczy zezwoliła na uprowadzenie lub zatrzymanie; lub
- dziecko przebywało w tym innym państwie co najmniej rok po tym, jak osoba, organ lub inna jednostka uprawniona do pieczy знаła lub powinna była znać miejsce jego pobytu, żaden wniosek o powrót zgłoszony w tym okresie nie jest już rozpatrywany, a dziecko zaadaptowało się do nowych warunków.

W zakresie ustalenia prawa właściwego Konwencja formułuje generalną zasadę, która pozwala organom i sądom właściwym (czyli tym, które mają jurysdykcję w danej sprawie) do stosowania przepisów swojego prawa (art. 15 ust. 1 Konwencji). Jednakże o ile ochrona osoby lub majątku dziecka tego wymaga, mogą one wyjątkowo

zastosować lub wziąć pod rozwagę prawo innego Państwa, z którym dana sytuacja ma ścisły związek (art. 15 ust. 2 Konwencji).

Powstanie, ustanie i wykonywanie odpowiedzialności rodzicielskiej podlega co do zasady prawu państwa zwykłego pobytu dziecka, co szczegółowo regulują art. 16 i 17 Konwencji.

SPORY W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIECI – JAK JE ELIMINOWAĆ NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO I PRZED SĄDAMI W POLSCE?

Zdecydowana większość sporów dotyczących dzieci pojawia się na kanwie decyzji rodziców o rozstaniu. Nawet najbardziej przemyślana i poparta merytorycznymi argumentami decyzja, niesie za sobą ładunek emocjonalny, co czyni sprawy rodzinne specyficznymi z psychologicznego punktu widzenia.

Z jednej strony pojawi się konflikt, o różnym stopniu nasilenia, pomiędzy rodzicami, z drugiej strony jest dziecko, które czeka na zmiany, nie mogące pozostać bez wpływu na jego sferę emocjonalną.

Decyzje podejmowane przez rodziców na tym etapie, są nierozzerwalnie związane z ukształtowaniem sytuacji ich dziecka. Brak porozumienia i nieumiejętność dokonania uzgodnień w istotnych sprawach, takich jak przyszłe miejsce pobytu dziecka, zakres wykonywania praw i obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów, zakres partycypowania w kosztach wychowania i utrzymania dziecka, zawsze pociąga za sobą niepotrzebne i często bardzo niekorzystne w skutkach, zaangażowanie dziecka. w sprawach spornych niejednokrotnie dochodzi do sytuacji wciągnięcia dziecka w konflikt związany z rozstaniem, nie mówiąc o przypadkach, gdzie dziecko staje się swego rodzaju „kartą przetargową”.

W takich sytuacjach idealnym rozwiązaniem jest wyjście przez rodziców ponad sferę konfliktu i przeniesienie ciężaru walki o racje, na walkę o relacje.

Jeżeli tylko rodzice są w stanie ze sobą rozmawiać, mogą samodzielnie wypracować porozumienie.

DZIECI POCHODZĄCE ZE ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH

Rodzice będący w związkach partnerskich mają największą swobodę w zakresie wypracowania porozumienia. z racji pozostawania w związku nieformalnym, nie muszą angażować sądu w jakimkolwiek zakresie, gdy chodzi o sprawy ich małoletniego dziecka.

Co do zasady, w większości przypadków, obojgu takim rodzicom przysługuje władza rodzicielska (o ile wcześniej nie została w żaden sposób ograniczona, zawieszona lub ustała na skutek orzeczenia sądu). Utrzymanie takiego stanu rzeczy nie wymaga w związku z tym, podjęcia jakichkolwiek dalszych kroków prawnych.

Rozstanie zwykle związane jest ze zmianą miejsca zamieszkania co najmniej jednego z partnerów, co determinuje potrzebę ustalenia, z którym z rodziców zamieszka dziecko i tym samym, które z rodziców będzie rodzicem wiodącym (w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem). w takim przypadku, warto zadbać o to, aby drugi z rodziców miał na tyle częste kontakty z dzieckiem, aby utrzymać dotychczasową więź, budować silną z nim relację i mieć realny wpływ na proces wychowawczy i sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Alternatywą dla ustalania miejsca pobytu dziecka przy jednym z rodziców, jest tzw. **opieka naprzemienna**, która polega na tym, że dziecko mieszka i przebywa u każdego z rodziców przez określony, ustalony pomiędzy rodzicami czas (np. tydzień na tydzień, miesiąc na miesiąc).

Wskazując na powyższe rozwiązanie, które **nie jest prawnie uregulowane na gruncie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego**, należy wskazać, że zarówno w doktrynie prawniczej, jak i ze strony psychologów pojawiają się odmienne głosy i opinie, co do zgodności opieki naprzemiennej z dobrem dziecka.

W związku z powyższym, decyzja o zastosowaniu tej metody sprawowania opieki nad dzieckiem, powinna być adekwatna do wieku dziecka, jego rozsądnych oczekiwań i osobistych predyspozycji oraz umiejętności funkcjonowania w środowisku „dwóch domów”.

Przyjęcie schematu opieki naprzemiennej wymaga także od rodziców zdecydowanie większego zaangażowania i współpracy, niż w przypadku ustalenia miejsca pobytu dziecka przy jednym z nich. Rodzice muszą mieć wzajemne zaufanie do siebie i wykazywać chęć współpracy, zapewniać przepływ informacji, dbać o spójność środowisk wychowawczych, tak aby dziecko miało poczucie, że jest członkiem dwóch środowisk domowych, w których jego potrzeby są uwzględniane. Decyzja w tym zakresie powinna być zatem gruntownie przemyślana.

Rodzice pozostający w związku partnerskim swobodnie mogą również ustalić pomiędzy sobą sposób i zakres partycypowania w kosztach wychowania i utrzymania dziecka lub dzieci. Łożenie alimentów niekoniecznie musi polegać na comiesięcznym przekazywaniu określonej kwoty pieniężnej i ograniczeniem roli jednego rodzica li tylko do tej czynności.

W praktyce może się to sprawdzać np. do założenie rachunku bankowego, na który co miesiąc wpłacana jest określona kwota pieniędzy przez każdego z rodziców i do którego oboje mają dostęp, celem finansowania wszystkich bieżących potrzeb dziecka. Rodzice mogą także podzielić się systematycznie występującymi wydatkami, np. jeden rodziców opłaca czesne za przedszkole, a drugi pokrywa wydatki związane ze wszystkimi zajęciami dodatkowymi, itp..

W przypadku opieki naprzemiennej, rodzice mogą w ogóle zrezygnować z przekazywania sobie pieniędzy (alimentów), zobowiązując się do pokrywania bieżących kosztów utrzymania dziecka przez tego rodzica, u którego dziecko w danym momencie przebywa i wspólnego pokrywania innych wydatków, w określonych z góry proporcjach (np. po połowie).

Jak wynika z powyższego, rodzice pozostający w związkach partnerskich mają niczym nieskrępowanie możliwości wypracowania porozumienia, samodzielnego podjęcia decyzji dotyczących najbliższej przyszłości swojej własnej i ich wspólnego dziecka lub dzieci. w sytuacji braku sporu pomiędzy rodzicami nie ma także konieczności formalizowania takich ustaleń.

DZIECI POCHODZĄCE ZE ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH

Na gruncie prawa polskiego jedyną możliwością rozwiązania małżeństwa jest orzeczenie rozwodu, które zapada w wyroku wydawanym przez sąd, po przeprowadzeniu postępowania, w toku którego sąd ustala, czy doszło do całkowitego i zupełnego ustania więzi małżeńskich (emocjonalnych, fizycznych i gospodarczych).

Innymi słowy rodzice, którzy podjęli decyzję o rozstaniu i zamierzają się rozwieść są zmuszeni skierować do sądu pozew, który zainicjuje postępowanie i zakończy się wydaniem wyroku.

W każdym przypadku, gdy z małżeństwa pochodzą dzieci, Sąd orzekając o rozwodzie musi zbadać, czy skutek rozwodu nie ucierpi dobro małoletnich dzieci stron (art. 56 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Nadto musi obligatoryjnie, w tym samym wyroku uregulować kwestie dotyczące małoletnich (art. 58 § 1 i 1b) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), tj.:

- rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem (dziećmi) obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem (z tym zastrzeżenie, że na zgodny wniosek stron sąd może odstąpić od orzekania o sposobie uregulowania kontaktów z dzieckiem);
- orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka;
- ustala miejsce pobytu dziecka (obligatoryjność orzeczenia w tym zakresie, jest przedmiotem dyskusji prowadzonej zarówno na płaszczyźnie doktrynalnej, jak i w orzecznictwie, co wykracza poza zakres niniejszego opracowania; autorka reprezentuje pogląd o konieczności rozstrzygnięcia tej kwestii w wyroku rozwodowym).

Sformalizowanie procedury rozwiązania małżeństwa stron i uregulowania sytuacji dziecka po rozwodzie nie oznacza, że rodzice nie mają wpływu na treść orzeczenia w tym zakresie.

Ustawodawca w art. 58 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidział zasadę, zgodnie z którą Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. w tym samym przepisie wprowadzono regułę, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Innymi słowy, podobnie jak w sytuacji rodziców pozostających w związkach partnerskich, także małżonkowie dysponują środkami samodzielnego uregulowania sytuacji ich dziecka lub dzieci w związku z podjętą decyzją o rozstaniu.

Opracowanie porozumienia rodzicielskiego nie jest szczególnie skomplikowane. w jego treści strony powinny ustalić:

- kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej (tj. czy wnioskuje o jej pozostawieniu obojgu rodziców, czy też decydują się na ograniczenie tej władzy jednemu z nich);
- miejsce stałego pobytu dziecka przy jednym z rodziców lub opiekę naprzemienną; w tym drugim przypadku należy dokładnie określić w jaki sposób (w jakich okresach czasowych) opieka ta będzie wykonywana przez każdego z rodziców;
- zakres partycypowania w kosztach utrzymania dziecka; przy czym w tym przypadku sposób określenia tego obowiązku nie jest dowolny – sąd w wyroku ustala w jakim zakresie tzn. jaką kwotę ma płacić co miesiąc, do określonego dnia (np. 10-go miesiąca) jeden rodzic do rąk drugiego rodzica celem zaspokojenia potrzeb dziecka, natomiast na drugiego rodzica nakłada obowiązek ponoszenia kosztów wychowania i utrzymania w pozostałym zakresie – w taki też sposób należałoby zatem precyzować postanowienia porozumienia w przedmiotowej kwestii;

- częstotliwości i sposób kontaktów z dzieckiem lub z dziećmi tego rodzica, przy którym dziecko lub dzieci nie będą miały ustalonego miejsca stałego pobytu – o ile jest taka potrzeba.

Dodatkowo, porozumienie rodzicielskie może służyć uszczegółowieniu pewnych obowiązków, np. kwestii dotyczących prowadzenia i odbierania dzieci z placówek edukacyjnych, z zajęć dodatkowych, podejmowania decyzji dotyczących dzieci w sprawach nie cierpiących zwłoki, wspólnego decydowania i współfinansowania wydatków, które nie mają bieżącego charakteru np. zakup komputera, roweru, sfinansowanie obozu sportowego itp. i innych kwestii, które wprawdzie nie są konieczne sądowi do wydania orzeczenia zgodnego z wolą stron, ale mogą pomóc w organizacji i ustaleniu reguł postępowania w sprawach dotyczących dzieci po rozwodzie.

Rzetelnie przygotowane porozumienie rodzicielskie, zawierające rozsądne postanowienia, niekontrowersyjne z punktu widzenia dobra dziecka rozwodzących się stron, najpewniej zostanie w całości uwzględnione przez sąd, co najdzie swój wyraz w treści kolejnych punktów wyroku rozwodowego.

W ten sposób małżonkowie mają realny wpływ na sposób uregulowania spraw swojego dziecka na czas po rozwodzie pomimo, że jest on nieco bardziej formalizowany, niż w przypadku, gdy do rozstania dochodzi pomiędzy rodzicami będącymi w związku partnerskim.

W tym miejscu warto również podkreślić, że zasady wypracowane w porozumieniu rodzicielskim i „przepisane” później do sentencji wyroku, nie są ustalane raz na zawsze. w związku z tym, nie powinna przerażać perspektywa, że spisując treść porozumienia dokonujemy ustaleń na bliżej nieokreślony czas.

Oczywiście warto uregulować sprawy tak, aby w miarę możliwości przewidzieć i wyeliminować sytuację zdezaktualizowania się postanowień w ciągu najbliższych miesięcy po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Jednak nawet gdyby taka sytuacja się zdarzyła, należy pamiętać, że w sytuacji gdy dojdzie do uzasadnionej zmiany okoliczności, można złożyć do sądu wnioski o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie dotyczącym władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu dziecka, alimentów i sposobu uregulowania kontaktów.

Przywołane powyżej przepisy, omówione zasady i podane przykłady znajdują także zastosowanie w sprawach o separację, która od rozwodu zasadniczo różni się tym, że na skutek orzeczenia nie dochodzi do rozwiązania związku małżeńskiego. Małżeństwo, jako stosunek prawny trwa nadal, natomiast w pozostałym zakresie powstają skutki takie, przy orzeczeniu rozwodu.

MEDIACJE = NIE MA PRZEGRANYCH

A co w przypadku gdy trudno o porozumienie?

Mediacje, mediacje i jeszcze raz mediacje.

Mediacje mogą być prowadzone zarówno przez małżonków, jak i życiowych partnerów. Postępowanie mediacyjne może być jedynym etapem wypracowywania porozumienia (bez formalizowania ustaleń przed sądem), etapem poprzedzającym postępowanie sądowe (gdy zamiarem stron jest wypracowanie porozumienia i sformalizowanie go przed sądem w formie orzeczenia) lub etapem postępowania sądowego.

Wynikiem mediacji mogą być ustalenia, które nie zostaną w żaden sposób sformalizowane (nawet pisemnie!), które mogą zostać spisane w formie umowy pomiędzy rodzicami, które mogą stać się podstawą porozumienia rodzicielskiego w sprawie rozwodowej albo mogą być zatwierdzone przez sąd lub wciągnięte do treści orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

Warunek jest jeden, mediacje w sprawach rodzinnych powinien być przeprowadzone przez specjalistę, biegłego w technikach prowadzenia mediacji, posiadającego umiejętności wytłumiania emocji stron, które zwykle stają na przeszkodzie

w osiągnięciu porozumienia. Mediator powinien pomóc stronom w znalezieniu kierunku, który doprowadzi je do rozwiązania, a nie narzucać treść porozumienia. Powinien być empatyczny, ale nie poddawać się emocjom oraz rozumieć istotę dobra dziecka i „stać na straży” tej wartości. nie może pośpieszać, ale z drugiej strony powinien konsekwentnie utrzymywać i nie pozwalać zmieniać kwestii już przez strony ustalonych, będąc przy tym umiarkowanie elastyczny. Mediator w sprawach rodzinnych powinien także postarać się dotrzeć do istoty sporu pomiędzy rodzicami, która często wcale nie jest objęta żądaniem pozwu lub wniosku, a tkwi zupełnie gdzie indziej.

Podstawowe problemy, które wpływają na niepodejmowanie przez rodziców w ogóle lub na fiasko mediacji to przede wszystkim:

- niedostateczna kampania informacyjna, brak świadomości rodziców czym jest mediacja, w jaki sposób przebiega, jakie są korzyści płynące z wypracowania porozumienia;
- brak świadomości rodziców o skutkach zaangażowania dziecka w konflikt okołorozwodowy oraz o konieczności zadbania o dziecko w tym szczególnie trudnym dla niego czasie;
- brak dostatecznej wiedzy i doświadczenia mediatorów prowadzących mediację w sprawach rodzinnych (stronniczość, zaangażowanie emocjonalne, ocenianie postaw rodziców, przedstawianie gotowych projektów porozumienia, brak dostatecznej wiedzy prawnej, aby przedstawić rodzicom co się wydarzy dalej w sądzie, jak nie dojdą do porozumienia oraz wiedzy psychologicznej, aby wyjaśnić stronom w jakiej sytuacji emocjonalnej znajduje się ich dziecko oraz jakie będą dalsze konsekwencje trwania przez rodziców, zarówno w relacjach między nimi, jak i w relacjach między każdym z rodziców a dzieckiem);
- brak zaangażowania profesjonalnych pełnomocników w propagowanie mediacji i innych form ugodowego rozwiązywania sporów;

- brak możliwości czasowych ze strony sędziów prowadzących sprawy rodzinne, do odbycia ze stronami rozmowy przed skierowaniem na mediacje (w większości spraw sądy kierują na mediacje po pierwszej wymianie pismo procesowych: pozew – odpowiedź na pozew lub wniosek – odpowiedź na wniosek; rodzice pozostający w sporze często są przekonani co do słuszności swoich racji i nie dopuszczają innych punktów widzenia tej samej sprawy (co gorsza, często są upewniani w tych racjach przez pełnomocników); na sali sądowej zderzają się z rzeczywistością, gdy sędzia przewodniczący składu orzekającego wyjaśni, że ta pewność siebie może być zgubna, że rację są co najmniej dwie i to sąd rozstrzygnie, która z nich jest słuszna; bardzo często dopiero wówczas do rodziców dociera świadomość, że wchodząc w spór pozostawiają podjęcie decyzji w swoich życiowych sprawach, w sprawach swoich dzieci osobie trzeciej – sędziemu, który wyda orzeczenie, z którego przynajmniej jedna ze stron nie będzie zadowolona; to często skłania do refleksji o podjęciu wysiłku w celu wypracowania dopuszczalnego kompromisu, na który strona ma wpływ i jest w stanie się na niego zgodzić.

W przeciwieństwie do spraw gospodarczych lub stricte majątkowych, mediacje rodzinne najlepiej wypadają bez udziału profesjonalnych pełnomocników. Wynika to z tego, o czym wspomniano już wcześniej, a mianowicie, że „kością niezgody” nierzadko są okoliczności w ogóle nie związane z zakresem żądań wyartykułowanych w pozwie lub we wniosku. Często dopiero „przepracowanie” istoty sporu, otwiera drogę do wypracowania porozumienia w sprawach objętych postępowaniem sądowym.

Rola pełnomocnika w sprawach rodzinnych powinna być niejako wtórna i powinna sprowadzać się do pomocy stronom w doprecyzowaniu i sformułowaniu postanowień ugody lub porozumienia, tak aby jej treść nadawała się do jej zatwierdzenia przez sąd,

lub w sytuacjach gdy nie jest to możliwe, do wciągnięcia do protokołu lub wyroku kończącego postępowanie sprawie.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIECI

A co w przypadku gdy porozumienie nie jest możliwe, rodzice nie chcą mediuwać albo mediacje nie przyniosły oczekiwanego rezultatu?

W sytuacji gdy nie sposób wypracować porozumienia, jak również w wtedy gdy okoliczności sprawy wskazują na zagrożenie dobra dziecka, zastosowanie znajdują przepisy i procedury, w oparciu o które rozstrzygnięcia spraw dotyczących dzieci dokona arbitralnie sąd w postępowaniu sądowym.

Do najczęstszych postępowań, jakie toczą się z w sprawach dotyczących dzieci należą:

1. postępowania w sprawie ustalenia miejsca pobytu dziecka lub dzieci;
2. postępowania o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
3. postępowania w sprawie o alimenty (ustalenie alimentów, podwyższenie/obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego);
4. postępowania w sprawie o uregulowanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

We wszystkich wyżej wymienionych postępowaniach, przy orzekaniu, Sąd w pierwszej kolejności bierze pod uwagę dobro dziecka. Podejmując decyzje nie kieruje się oczekiwaniami i potrzebami rodziców, ale przede wszystkim podejmuje działania optymalizujące sytuację dziecka.

Przed podjęciem decyzji o wyborze rodzica, przy którym ustala się miejsce pobytu dziecka, lub któremu powierza się mu władzę rodzicielską, sąd musi dokonać oceny kompetencji wychowawczych każdego z nich. w razie potrzeby, a tak dzieje się w przeważającej większości spraw, sąd w toku postępowań weryfikuje powyższe w oparciu o opinie biegłych pedagogów, psychologów i lekarzy psychiatrów albo korzystając z badań i ekspertyz wydawanych przez Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów (instytucja działająca przy Sadach Okręgowych).

Cytując za Jolantą Sasiak (w: Fras Mariusz (red.), Habdas Magdalena (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz - opublikowany w systemie informacji prawnej LEX):

w literaturze przedmiotu podkreśla się, że przedmiot i zakres opinii w sprawach dotyczących uregulowania szeroko rozumianej opieki nad dziećmi powinny obejmować ocenę rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka, ocenę kompetencji wychowawczych rodziców oraz przewidywanych warunków w nowych środowiskach wychowawczych stworzonych przez rodziców. Dopiero diagnoza tych elementów pozwala odnieść się do oczekiwań sądu, tzn. wskazać osobę lepiej przygotowaną do pełnienia roli opiekuna wiodącego, zaproponować zakres uprawnień drugiego z rodziców do udziału w wychowaniu, w tym częstotliwość oraz formę kontaktów z dziećmi, oraz przedstawić sugestie dotyczące relacji z innymi osobami, korygowania błędów wychowawczych i potrzeby korzystania z pomocy specjalistycznej (opieki społecznej, poradnictwa, mediacji czy terapii).

W sprawie dotyczących dzieci najczęściej sąd zwraca się do biegłych o wskazanie:

1. stanu emocjonalnego dziecka, jego przygotowania do rozłącznego funkcjonowania rodziny, psychologicznych przeciwwskazań dotyczących udzielenia rozvodu;
2. rodzaju więzi łączących każdego rodzica z dzieckiem;
3. oceny kompetencji wychowawczych rodziców, ich dyspozycji psychicznych;
4. z perspektywy psychologicznych potrzeb dziecka możliwości przyjęcia naprzemiennej pieczy nad dzieckiem;
5. psychologicznych czynników przemawiających na rzecz zastosowania określonych form i zakresu pieczy nad dzieckiem i kontaktów rodzica z dzieckiem, akceptowalnych przez rodziców i dziecko i adekwatnych do jego potrzeb;
6. specyficznych problemów wymagających podjęcia oddziaływań terapeutycznych w stosunku do dziecka lub rodziny.

Biegli, celem wydania opinii przeprowadzają badanie z udziałem zarówno obojga rodziców, jak i dzieci (o ile ich wiek umożliwia interakcje i podjęcie rozmowy, lub co najmniej obserwację zachowania). Badania odbywają się albo w gabinetach biegłych, albo w przypadku badań przeprowadzanych przez OZSS w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach. Rozmowa, zwykle poprzedzona rozwiązywaniem testów, jest przeprowadzana z osobą z każdym z rodziców ora z dzieckiem.

Po przeprowadzeniu badania, biegli sporządzają opinię na piśmie, która przekazywana jest do Sądu, uzyskując w ten sposób walor środka dowodowego.

W praktyce opinia wydana przez biegłych sądowych przesadzą o wyniku postępowania. Sądy zwykle opierają na tych ekspertyzach swoje rozstrzygnięcia, przywołując w uzasadnieniach wyroków i orzeczeń poszczególne fragmenty opinii. Rzadko kiedy zdarza się, aby sąd orzekł odmiennie, niż wskazują na to wnioski końcowe opinii biegłych.

W tym miejscu na uwagę zasługuje również instytucja wysłuchania dziecka uregulowana w art. 216¹ kodeksu postępowania cywilnego oraz w art. 576 Kodeksu postępowania cywilnego, który obejmuje swoim zakresem także postępowania nieprocesowe w sprawach dotyczących majątku dziecka.

Sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych.

Sąd stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia.

Przedstawiona przez dr Marcina Cieślińskiego analiza praktyki sądowej wskazuje, że sądy zazwyczaj podejmują decyzję o wysłuchaniu, działając z urzędu. Strony czy pełnomocnicy stron zachowują znaczną powściągliwość w zgłaszaniu wniosków o wysłuchanie. Przeprowadzone badanie ujawniło, że w ocenie sędziów wysłuchanie dziecka zwiększa szanse ustalenia w sposób właściwy okoliczności faktycznych sprawy, a w konsekwencji ułatwia wydanie trafnego rozstrzygnięcia. Wyniki badań aktowych wskazywały, że bezpośrednie wysłuchanie dzieci miało zazwyczaj istotny wpływ na wynik sprawy i doprowadziło w większości przypadków do uwzględnienia życzeń dziecka wyrażonych podczas przesłuchania lub częściowego uwzględnienia tych życzeń (cytuję za: Jolanta Sasiak w: Fras Mariusz (red.), Habdas Magdalena (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz)

Z drugiej strony w literaturze wskazuje się na możliwość wystąpienia potencjalnego ryzyka wywołania urazów psychicznych u dzieci biorących udział w postępowaniu sądowym właściwych dla kolejnych faz rozwoju dziecka. z drugiej strony zwraca się uwagę na to, że pomimo dominującego przekonania o potencjalnym ryzyku dla psychiki młodego człowieka związanym z jego osobistym udziałem w sprawie w badaniach wykazano jednak, że dzieci chcą wypowiadać się w sprawach dla nich istotnych, a zapewnienie właściwych warunków wysłuchania i wsparcie dorosłych może pomóc dziecku odnaleźć się w tej trudnej sytuacji (tak: Jolanta Sasiak w: Fras Mariusz (red.), Habdas Magdalena (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz)

Do spraw rodzinnych angażuje się także kuratorów, którzy na zlecenie Sądu przeprowadzają wywiady środowiskowe, z których sporządzają sprawozdania dotyczące bieżącej sytuacji dziecka i jego rodziców, warunków mieszkaniowych, zdrowotnych, itp.

Kurator sądowy, działając na polecenie sądu, udaje się do miejsca zamieszkania dziecka lub do miejsca, w którym dziecko przebywa raz na jakiś czas, lub potencjalnie mogłoby przebywać w przyszłości na stałe. Podczas wizyty, kurator rozmawia z rodzicem lub rodzicami oraz dzieckiem. Rozmowa taka zwykle przeprowadzana jest na osobności. Jak wynika z powyższego, standardowe procedury stosowane w sporach sądowych, angażują nie tylko rodziców pozostających w sporze, ale także dziecko. nie ma przy tym możliwości, aby odmówić udziału dziecka w tych badaniach. Niestawiennictwo lub sprzeciwienie się badaniu może zostać odebrane, jako nadużywanie władzy rodzicielskiej.

Celem postępowania jest ustalenie, przy którym z rodziców dziecko ma mieć miejsce stałego pobytu, tzn. z kim będzie mieszkać i gdzie będzie jego środowisko domowe. *De facto* wydane w takiej sprawie orzeczenie wskazuje rodzica wiodącego, ponieważ to z nim dziecko będzie spędzało większość czasu. Ten rodzic siłą rzeczy będzie bardziej

obciążony bieżącymi obowiązkami, ale także będzie miał większy wpływ na wychowanie dziecka.

Sądowe ustalenie miejsca pobytu dziecka staje się zazwyczaj konieczne, gdy oboje rodzice spierają się między sobą o to, z którym z nich dziecko ma zamieszkać. Nierzadko postępowanie sądowe jest poprzedzone sytuacjami, w którym rodzice podejmowali próby usankcjonowania miejsca pobytu dziecka samodzielnie, poprzez jego fizyczne zabranie spod opieki drugiego rodzica i równoległym braku przyzwolenia na jego odebranie.

Sądowe ustalenie miejsca pobytu dziecka jest kluczowe w sprawach porwań rodzicielskich, w szczególności objętych procedurą konwencji haskiej.

Zgodnie z brzmieniem art. 107 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

W braku porozumienia, o którym mowa powyżej sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

W sytuacjach przemijającej przeszkody, sąd może ingerować we władzę rodzicielską poprzez jej zawieszenie (art. 110 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), natomiast jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe

obowiązków względem dziecka, sąd opiekuńczy może pozbawić jednego lub obojga rodziców władzy rodzicielskiej (art. 111 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Postępowania sądowe mające za przedmiot obowiązków alimentacyjny, zasadniczo sprowadzają się do badania trzech kluczowych kwestii, mających bezpośrednie przełożenie na wysokości ustalonych przez Sąd alimentów.

W każdej ze spraw, zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 135 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Sąd ustala:

- możliwości zarobkowe rodziców, które są oceniane nie przez pryzmat aktualnego zatrudnienia (np. za wynagrodzeniem w wysokości najniższej krajowej), ale z uwzględnieniem faktycznego wykształcenia, posiadanego zawodu, kursów, szkoleń doświadczenia zawodowego i dotychczasowej historii zatrudnienia);
- usprawiedliwione potrzeby dziecka, przez które rozumie się faktycznie ponoszone wydatki związane z wychowaniem i utrzymaniem dziecka w zakresie jego bieżących potrzeb (uśrednione do okresów miesięcznych);
- stopę życiową obojga rodziców w związku ze stosowaniem zasady „równiej stopy życiowej rodziców i dzieci”; przez pryzmat tej zasady ocenia się także wysokości usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

W wyroku Sąd wskazuje rodzica zobowiązanego do alimentacji, precyzuje kwotę alimentów, z reguły płatną miesięcznie, do określonego dnia miesiąca, do rąk drugiego rodzica, wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty.

W przypadku zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), jak również uchylecia obowiązku alimentacyjnego, w sytuacji gdy odpadły przesłanki alimentacji (np. dziecko jest już w stanie utrzymać się samodzielnie lub żądanie

alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego). nie dotyczy to jednak obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.

Zmiana orzeczenia może polegać na podwyższeniu albo na obniżeniu renty alimentacyjnej. Uzyskanie takie rozstrzygnięcia jest możliwe jedynie wtedy, gdy doszło do zmiany okoliczności faktycznych, które legły u podstaw wydania wcześniejszego rozstrzygnięcia precyzującego wysokość obowiązku alimentacyjnego (np. zmiana możliwości zarobkowych rodziców, wzrost usprawiedliwionych potrzeb dziecka, częściowe osiągnięcie możliwości samodzielnego utrzymania się).

Potrzeba sądowego uregulowania kontaktów pojawia się zwykle wtedy, gdy rodzic wiodący, z którym dziecko zamieszkuje, utrudnia wykonywanie kontaktów drugiemu z rodziców. w takiej sytuacji ingerencja sądu może okazać się daleko idąca i zawsze jest precyzyjna.

Sąd orzekający w takiej sprawie ustala jaki sposób i zakres kontaktów dziecka z rodzicem będzie dla niego najlepszy i zarazem adekwatny do wieku, posiadanych obowiązków, zajęć dodatkowych i trybu życia. Punktem wyjścia w sprawach o uregulowanie kontaktów, jest zasada, że prawo do kontaktów pomiędzy rodzicami i dziećmi, jest nie tylko uprawnieniem rodzica, ale także uprawnieniem dziecka. Stąd nawet rodzice pozbawienie władzy rodzicielskiej, zachowują prawo do kontaktów z dzieckiem, o ile nie zagraża to ich dobru (art. 113 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem (art. 113² kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

1. zakazać spotykania się z dzieckiem;
2. zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
3. zezwolić na spotkanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;

4. ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
5. zakazać porozumiewania się na odległość.

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaze ich utrzymywania (art. 113³ kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Jak już wspomniano powyżej uregulowanie kontaktów jest bardzo precyzyjne. w zależności od zakresu i szczegółowości żądania zawartego we wniosku rodzica, polega na ustaleniu harmonogramu spotkań w tygodniu, w weekendy, w okresach świąt, wakacji, ferii zimowych oraz w innym czasie istotnym dla rodziców. Sąd określa dokładnie godziny tych spotkań (od – do) oraz to czy mają się one odbywać w miejscu zamieszkania dziecka czy też poza nim.

Orzeczenie sądu (ale także ugoda) wydane w sprawie o uregulowanie kontaktów daje nie tylko uprawnienie do wykonywania kontaktów z dzieckiem, ale także formułuje obowiązek odbywania spotkań w terminach przez sąd zakreślonych.

Inicjując jakiegokolwiek postępowanie sądowe w sprawach dotyczących dzieci, należy zawsze liczyć się z tym, że niezależnie od zakresu żądania sformułowanego we wniosku lub w pozie, Sąd może podjąć równoległe postępowanie z urzędu. Efektem takiej możliwości może być np. sytuacja, w której na skutek wszczęcia postępowania w sprawie o uregulowanie kontaktów, Sąd stwierdzi ograniczone kompetencje wychowawcze obojga rodziców i ograniczy im władzę rodzicielską względem ich małoletniego dziecka.

W praktyce spotyka się sytuacje, w których brak porozumienia między rodzicami i przedkładanie konfliktu pomiędzy nimi nad dobro dziecka oraz angażowanie małoletniego w spór, kończyło się orzeczeniem w sprawie umieszczenia dziecka

w pieczy zastępczej, gdyż w ocenie Sądu środowisko rodzinne miało degradujący wpływ na psychikę i rozwój emocjonalny dziecka.

Zakres działania Sądu jest szeroki. w każdej sytuacji gdy dobro dziecka jest zagrożone, Sąd może wydać odpowiednie zarządzenie.

W art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podaje się przykłady takich rozstrzygnięć, a mianowicie sąd opiekuńczy może w szczególności:

1. zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
2. określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
3. poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
4. skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;
5. zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo

- zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej;
6. powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.

Powyższe prowadzi do konkluzji, że wszczynanie postępowań sądowych może się okazać niepewne w skutkach, kosztowne i długotrwałe. Zwykle odbywa się ze szkodą dla dziecka, które jest angażowane w spór rodziców nie tylko w warunkach domowych, ale także poprzez konieczność uczestniczenia w czynnościach procesowych (badania przez biegłych, instytucja wysłuchania dziecka).

Stąd tak istotne jest uświadamianie rodzicom siły konsensusu i porozumienia, które sprzyja budowaniu relacji i umożliwia zgodne współdziałanie w sprawach dotyczących dziecka, którym rodzice będą związani praktycznie przez całe życie.

PRZYDATNE LINKI:

www.eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl Baza aktów prawnych Unii Europejskiej;

<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp> Baza krajowych aktów prawnych.

Informacje dodatkowe do materiału audiowizualnego dotyczącego

INSTYTUCJI OCHRONY DZIECI I RODZINY

NIEMCY

Jugendamt to niemiecka instytucja odpowiedzialna za ochronę i wsparcie dzieci i młodzieży. Jego głównym celem jest zapewnienie dobrobytu dzieci oraz ochrona ich praw i interesów. Jugendamt jest instytucją, która istnieje w każdym powiecie i gminie w Niemczech. Jej kompetencje obejmują szeroki zakres dziedzin, takich jak ochrona dzieci, opieka nad dziećmi, wsparcie rodzinne, edukacja, adopcja, opieka nad dziećmi w placówkach oraz interwencja w przypadku sytuacji kryzysowych. Główne zadania tej instytucji to:

Ochrona dzieci

Jugendamt działa w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed wszelkimi formami przemocy, zaniedbania czy nadużyć.

Wsparcie rodzinne

Instytucja oferuje wsparcie i pomoc rodzinom w różnych obszarach, takich jak opieka nad dziećmi, wychowanie, doradztwo rodzinne, mediacje rodzinne oraz organizacja zajęć i programów edukacyjnych dla rodziców.

Placówki opiekuńcze

Jugendamt nadzoruje placówki opiekuńcze, takie jak domy dziecka, rodzinne domy zastępcze i inne formy doraźnej opieki nad dziećmi, które wymagają tymczasowego lub długoterminowego wsparcia.

Adopcja

Instytucja jest zaangażowana w proces adopcyjny, w tym ocenę i przygotowanie rodzin adopcyjnych oraz koordynację adopcji międzynarodowych.

Wsparcie edukacyjne

Jugendamt zapewnia wsparcie i usługi edukacyjne, takie jak doradztwo zawodowe, programy wsparcia edukacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Obowiązek zgłaszania

Jugendamt posiada obowiązek zgłaszania wszelkich podejrzeń nadużyć, zaniedbań lub przemocy wobec dzieci. Jeśli instytucja otrzyma informacje o takich przypadkach, ma obowiązek podjąć działania w celu ochrony dziecka i zapewnienia mu odpowiedniej pomocy.

Współpraca

Jugendamt działa we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, takimi jak szkoły, służby zdrowia, policja, sądy i organizacje pozarządowe. Współpraca ta ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia dla dzieci i rodzin oraz koordynację działań w przypadkach złożonych.

Rola Jugendamt w przypadku porwań rodzicielskich

Zgłoszenie i interwencja

Jeśli rodzic zgłasza porwanie rodzicielskie dziecka do Jugendamt, instytucja ta ma obowiązek podjąć interwencję. Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowe informacje dotyczące porwania, takie jak tożsamość osoby porwanej, tożsamość

i relacja porwanej osoby do porywającego rodzica, miejsce i czas porwania, obawy dotyczące bezpieczeństwa dziecka itp.

Współpraca z organami ścigania

Jugendamt współpracuje z organami ścigania, takimi jak policja i sądy, w celu odzyskania porwanego dziecka i zapewnienia jego bezpieczeństwa. Informacje i dowody zgromadzone przez Jugendamt są przekazywane odpowiednim organom ścigania, które podejmują działania w celu odnalezienia dziecka i przywrócenia go do rodzica-opiekuna.

Współpraca z innymi państwami

Jeśli porwanie rodzicielskie ma charakter transgraniczny, Jugendamt współpracuje z odpowiednimi instytucjami w innych państwach w celu koordynacji działań. w takich przypadkach stosuje się międzynarodowe umowy i konwencje, takie jak Konwencja Haski o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka z 1980 roku.

Interwencja w interesie dziecka

W przypadku porwań rodzicielskich Jugendamt działa zawsze w najlepszym interesie dziecka. Jeśli dziecko zostało porwane przez jednego z rodziców, Jugendamt może zastosować różne środki, takie jak mediacje, negocjacje, interwencje prawne czy nadzór, w celu zapewnienia, że dziecko jest bezpieczne i znajduje się we właściwym środowisku opieki.

Wsparcie i pomoc rodzinie

Jugendamt oferuje również wsparcie i pomoc rodzinie w sytuacji porwania rodzicielskiego. Mogą to być usługi psychologiczne, doradztwo, porady prawne i inne formy wsparcia emocjonalnego i prawnego, aby rodzina mogła skutecznie radzić sobie z tak trudną sytuacją.

WIELKA BRYTANIA

W Wielkiej Brytanii istnieje wiele organizacji i agencji rządowych odpowiedzialnych za ochronę i wsparcie dzieci, w tym Child Services. Jedną z głównych agencji w tej dziedzinie jest NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) oraz lokalne władze samorządowe, które są odpowiedzialne za świadczenie usług dla dzieci i ich rodzin. Główne zadania tej instytucji to:

Ochrona dzieci

Child Services ma za zadanie zapewnić ochronę i dobrostan dzieci. Ich priorytetem jest identyfikacja i zapobieganie przypadkom nadużyć, zaniedbań, przemocy lub wyzysku wobec dzieci.

Zgłaszanie przypadków

Child Services otrzymuje zgłoszenia dotyczące potencjalnych przypadków nadużyć, zaniedbań lub innych form przemocy wobec dzieci. Zgłoszenia mogą pochodzić od osób związanych z dzieckiem, takich jak nauczyciele, pracownicy służby zdrowia czy sąsiedzi, ale również od samego dziecka. Zgłoszenia są traktowane jako poufne, a pracownicy Child Services przeprowadzają dochodzenie w celu oceny sytuacji i podjęcia odpowiednich działań.

Ocena potrzeb

Po otrzymaniu zgłoszenia, Child Services przeprowadza ocenę potrzeb dziecka i rodziny. Dochodzenie może obejmować rozmowy z dzieckiem, członkami rodziny, nauczycielami, pracownikami służby zdrowia i innymi osobami mającymi wiedzę na temat sytuacji dziecka. Celem jest zrozumienie, czy dziecko jest zagrożone i jakie środki wsparcia są konieczne.

Interwencja i wsparcie

W zależności od wyników oceny, Child Services może podjąć różne działania. Mogą to być interwencje bezpośrednie, takie jak umieszczenie dziecka pod opieką instytucji opiekuńczej, zabezpieczenie go przed dalszymi nadużyciami lub udzielanie pomocy rodzinie w celu poprawy warunków życia dziecka. Child Services może również zapewnić wsparcie emocjonalne, psychologiczne, prawnicze i inne usługi dla rodziny, aby pomóc jej w radzeniu sobie z trudnościami.

Współpraca z innymi instytucjami

Child Services współpracuje z innymi instytucjami, takimi jak policja, sądy, placówki oświatowe i służba zdrowia, w celu zapewnienia kompleksowego i koordynowanego podejścia do ochrony i wsparcia dzieci.

Rola Child Services w przypadku porwań rodzicielskich

Zgłoszenie i interwencja

Jeśli rodzic zgłasza porwanie rodzicielskie dziecka do Child Services, organ ten natychmiast podejmuje działania w celu odzyskania dziecka i zapewnienia mu bezpieczeństwa. Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowe informacje na temat porwania, takie jak tożsamość osoby porwanej, tożsamość i relacja porwanej osoby do porywającego rodzica, miejsce i czas porwania, obawy dotyczące bezpieczeństwa dziecka itp.

Współpraca z organami ścigania

Child Services ściśle współpracuje z organami ścigania, takimi jak policja, w celu odnalezienia porwanego dziecka i przywrócenia go do rodzica-opiekuna. Organizacje te wymieniają informacje, udzielają sobie wsparcia i podejmują wspólne działania w celu skutecznego odzyskania dziecka.

Monitorowanie i nadzór

Child Services prowadzi nadzór i monitoruje sytuację dziecka po odzyskaniu, aby upewnić się, że znajduje się w bezpiecznym i odpowiednim środowisku. Mogą być stosowane różne środki, takie jak umieszczenie dziecka pod opieką członków rodziny, tymczasowe umieszczenie w placówce opiekuńczej lub udzielanie wsparcia i poradnictwa rodzinie w celu zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa dziecka.

Wsparcie dla rodzica / opiekuna

Child Services oferuje wsparcie emocjonalne, poradnictwo i pomoc prawną rodzicowi / opiekunowi w przypadku porwania rodzicielskiego. Działa w najlepszym interesie dziecka, zapewniając rodzinie niezbędne narzędzia i informacje dotyczące procesu prawnoustrojowego oraz dostęp do innych usług wsparcia.

Współpraca międzynarodowa

Jeśli porwanie rodzicielskie ma charakter transgraniczny, Child Services współpracuje z odpowiednimi instytucjami i organami w innych krajach w celu koordynacji działań. Wykorzystuje się międzynarodowe porozumienia i konwencje w celu odzyskania dziecka i zapewnienia jego bezpieczeństwa.